

1508087-31.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... exagerada a ponto de indicar a vinculação com o tráfico. O réu, por sua vez, negou envolvimento no tráfico, admitindo a posse para o uso pessoal em seu interrogatório judicial. A quantidade não é, por si, incompatível com aquela condição.

Assim, qualquer afirmação de tráfico haveria de partir, necessariamente, de uma presunção, que, como se sabe, não se mostra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508087-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508087-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090099/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 17121016 - 13º D.P. CASA VERDE, 1355/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2090099 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

VINICIUS CAUE PERETO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c art. 41 do Código de Processo Penal, em face de Luiz Otávio da Silva e de Vinícius Cauê Pereto Pereira - ambos qualificado e representados nos autos -, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 171 do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, respectivamente.

De acordo com a denúncia de fls. 1-144-150 oferecida pelo Parquet:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de abril de 2021, por volta das 17h20min, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Antonelo da

Messina, 1047, Tremembé, nesta cidade e comarca da capital, LUIZ OTAVIO DA SILVA, qualificado a fls. 44, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com uma mulher não identificada, obteve, para proveito comum, vantagem ilícita, no valor de R\$ 1.038,54 (hum mil e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em prejuízo da empresa vítima Promofarma, representada por Jamile da Silva Souza, mediante o meio fraudulento a seguir descrito, conforme reconhecimento pessoal realizado no termo de declarações a fls. 05, fotografias a fls. 17/18, comprovante de pagamento fraudado a fls. 20/21, auto de exibição e apreensão a fls. 23/24, auto de entrega a fls. 25 e auto de avaliação a fls. 26.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de abril de 2021, por volta das 21h00min, em ocasião de calamidade pública, a Rua Sampaio Correa, 94, Limão, nesta cidade e comarca da capital, VINICIUS CAUE PERETO PEREIRA, qualificado a fls. 33, trazia consigo, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 04 (quatro) "tabletes" de maconha, com peso líquido de 73.1g (setenta e três gramas e um decigrama), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme fotografia a fls. 15, auto de exibição e apreensão a fls. 23/24 e laudo de constatação a fls. 28/30.

Segundo o apurado, na data dos fatos, em ocasião de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo vírus Covid-19, LUIZ OTAVIO se conluiou com mulher não identificada, para a prática de golpes a estabelecimentos comerciais. Nesta oportunidade, a agente não identificada, se apresentando como "Márcia Mendes" e utilizando a linha telefônica (11) 95841-2001, realizou a compra fraudulenta de produtos perante a empresa vítima, no valor de R\$ 1.038,54 (hum mil e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), por meio do aplicativo WhatsApp de mensagens, enviando, para tanto, um comprovante de transferência bancária contrafeito.

Assim que, realizada a compra fraudulenta, o denunciado LUIZ OTAVIO, se apresentando falsamente como "Renato", se dirigiu pessoalmente ao estabelecimento comercial vítima para retirar a mercadoria, obtida ilicitamente.

Por sua vez, o denunciado VINICIUS CAUE deu carona à LUIZ OTAVIO, o levando ao estabelecimento vítima, a bordo do veículo Hyundai/HB20, placas FRB 5361, sem ter ciência do golpe aplicado.

Já por volta das 21h00min, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Rua Eulálio da Costa de Carvalho, visualizaram o referido veículo ocupado pelos denunciados, em atitude suspeita, eis que não obedeceram ao sinal de parada, contudo, após breve acompanhamento, o referido automóvel foi abordado na Rua Sampaio Correa, 94.

Ato contínuo, durante a abordagem, em revista pessoal, os policiais localizaram em poder de LUIZ OTAVIO as mercadorias obtidas ilicitamente. E ainda, VINICIUS CAUE informou aos milicianos que, no interior do porta-luvas do automóvel, estavam guardadas as substâncias entorpecentes de sua propriedade, bem como portava a quantia de R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

As circunstâncias da prisão em flagrante, as apreensões de considerável quantidade de entorpecentes em poder do denunciado, além de valor em espécie, evidenciam o intuito da mercancia ilícita.

Interrogado em sede policial, LUIZ OTAVIO confessou a prática do estelionato em comparsaria com pessoa não identificada e explicou como agia para a prática dos golpes em prejuízo dos estabelecimentos comerciais, inclusive apontando que utilizava uma conta bancária fraudulenta em nome de terceiro, bem como fraudava os comprovantes de pagamento, a fls. 06.

Por sua vez, interrogado em sede policial, VINICIUS CAUE negou a prática do tráfico de drogas, alegando que as substâncias entorpecentes eram destinadas para uso pessoal dele e de um amigo de prenome "Gabriel", vez que entregaria parte dos entorpecentes a ele, a fls. 07. (...)"

Presos em flagrante, foi concedida liberdade provisória aos acusados (fls. 95-97) Recebida a denúncia, determinou-se a citação dos réus (fls. 163-164).

Os denunciados apresentaram resposta à acusação.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), designou-se audiência de instrução e julgamento.

Durante a audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, foi realizado o interrogatório dos acusados. As alegações do Parquet e da Defesa constaram no termo de fls. 282-286 e às fls. 278-281. Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

1. Da imputação relativa à prática do delito de estelionato

A materialidade está positivada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fl. 1), as imagens de fls. 17-18, o auto de exibição e apreensão (fls. 23-24) e o o auto de avaliação (fl. 26).

A autoria é certa.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Jamile da Silva Souza relatou que uma mulher denominada Márcia efetuou um pedido por telefone, prometendo o pagamento via pix. Informou, porém, que o pagamento não foi debitado. Relatou que um sujeito buscou os produtos no seu estabelecimento. Declarou que Luiz Otávio desceu do carro e retirou a mercadoria. Asseverou que o corréu Vinicius Cauê permaneceu no interior do veículo. Algumas horas depois, policiais entraram em contato, dizendo que a mercadoria foi apreendida e que o comprovante de pagamento era falso. Em seguida, foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. Os produtos foram recuperados.

Paulo Henrique Queiroz (PoliciaI Militar) relatou que estava em patrulhamento, quando avistou os réus no interior de um veículo. Disse que os réus não respeitaram a sinalização de “pare”, o que lhe chamou a atenção. Decidiu abordá-los. Em relação ao crime de estelionato, declarou que, na busca veicular, encontrou duas sacolas contendo produtos farmacêuticos. A propósito do pagamento dos produtos farmacêuticos, o acusado Luiz Otávio apresentou um comprovante de pix, o qual se mostrou nitidamente falso devido a erros de formatação. Afirmou que entrou em contato com a gerente da farmácia e perguntou sobre a compra dos produtos, o que foi confirmado pela funcionária; esta, por sua vez, contou que um sujeito comprou produtos mediante pagamento por pix. Então, em seguida, informou a gerente de que o pagamento era falso, e ela confirmou que o pagamento não foi debitado. Declarou que o réu Luiz Otávio confessou informalmente o “golpe”.

Matheus Donaton Delfino (PoliciaI Militar) disse que estava em patrulhamento. Conseguiu abordar o veículo na Rua Sampaio Correia. Disse que fez uma busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Na busca veicular, porém, localizou produtos farmacêuticos. Contou que Vinicius conduzia o carro, e Luiz Otávio estava no banco do passageiro. Em relação aos medicamentos, respondeu que estavam numa sacola e outra parte espalhada dentro do veículo. Tais produtos pertenciam a Luiz Otávio. Este afirmou que se valia de comprovante falso e retirava os produtos na farmácia.

Após conversa reservada com seu patrono e cientificado dos seus direitos constitucionais, o acusado Luiz Otávio da Silva confessou o estelionato. Respondeu que foi preso em flagrante. Declarou que o corréu é seu vizinho e pediu para ele fazer uma corrida até a farmácia.

Nota-se, pois, que o mosaico probatório não deixa dúvidas quanto à responsabilidade criminal de Luiz Otávio. A prova documental produzida no curso do inquérito, especialmente o auto de exibição e apreensão, demonstra a posse de produtos farmacêuticos retirados do estabelecimento no qual Jamile da Silva trabalhava, pessoa que, inclusive, entregou os bens ao denunciado. As testemunhas e sobretudo a vítima destacaram o golpe empregado, consistente no envio de comprovante falso de pagamento. Ademais, o próprio acusado confessou a conduta delitativa.

O elemento central do estelionato é a fraude ou o ardil. Por meio desse instrumento, o agente coloca a vítima em erro e, conseqüentemente, obtém vantagem patrimonial ilícita. Em outros termos: é indispensável que a vantagem econômica obtida, além de ilícita, seja decorrente de um erro produzido pelo sujeito.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt ensina que:

“(...) para caracterização do estelionato, cabe à acusação comprovar os seguintes

elementos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (...)" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 3 : parte especial : dos crimes contra o patrimônio. 12 ed. São Paulo: Saraiva. 2012. Epub)

In casu, consoante já sinalizado, o ardil envolveu a utilização de comprovante falso de pagamento via pix, fato que teve o condão de enganar Jamile da Silva e, com isso, possibilitou a entrega dos produtos ao acusado, causando prejuízo econômico à vítima.

Sendo assim, no tocante à tipicidade, entendo que o réu, com consciência e vontade, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, induziu, mediante ardil, os funcionários do estabelecimento Promofarma, causando prejuízo à vítima, motivo pelo qual sua conduta se amoldou ao disposto no art. 171, caput, do Código Penal. Assim, à luz da teoria da indiciabilidade, praticada a conduta típica, presume-se antijurídica, salvo se afastada a ilicitude pela prova produzida nos autos. No caso em apreço, não restou demonstrada a presença de nenhuma excludente.

A culpabilidade, como pressuposto de aplicação da pena, é indiscutível. O réu era imputável no momento da ação, gozando de capacidade para entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com tal entendimento, sendo-lhe exigível conduta diversa.

Conforme se depreende da certidão de fls. 66-67, o réu é primário.

Considerando que a declaração dada pelo réu contribuiu para formação do convencimento do juízo, de rigor o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Não incide a agravante da calamidade pública, uma vez que não há nexos entre a situação da pandemia e o estelionato, ou seja, o advento da covid-19 não facilitou a prática da fraude perpetrada pelo denunciado.

A propósito:

SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT,) - RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - RÉ QUE AGIU COM DOLO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A INTENÇÃO DA APELANTE EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA INDUZINDO A VÍTIMA A ERRO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA - POSSIBILIDADE - NÃO SE TRATA DE UM CRITÉRIO TEMPORAL OBJETIVO - NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SE APROVEITOU DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FRAGILIDADE, VULNERABILIDADE OU INCAPACIDADE GERADAS PELO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 - RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1514775-92.2020.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

2. Da imputação relativa ao tráfico de drogas

A materialidade está demonstrada a partir do auto de prisão em flagrante (fl. 1), as imagens de fls. 17-18, o auto de exibição e apreensão (fls. 23-24) e do laudo pericial 115177/2021. Do exame desses documentos, conclui-se que foram encontrados 4 tabletes contendo 73,1g de massa líquida, na qual foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol, substância de uso proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria é igualmente certa.

Paulo Henrique Queiroz (Policia Militar) relatou, no tocante aos entorpecentes, que 4 (quatro) tabletes de maconha foram encontrados no porta-luvas do veículo conduzido por Vinicius. Indagado, o réu alegou que o produto se destinava ao seu próprio consumo. A testemunha afirmou que a embalagem parecia destinada à venda. Perguntado, respondeu que não havia material de endolação, como, por exemplo, balança de precisão.

Matheus Donaton Delfino (Policial Militar) disse que também localizaram dinheiro em espécie estava na carteira de Vinicius. No tocante ao entorpecente, Vinicius sustentou que a droga era de consumo próprio.

Após conversa reservada com seu patrono e cientificado dos seus direitos constitucionais, o Vinicius Caue Pereto Pereira disse que Luiz Otávio é seu vizinho. Afirmou que trabalhava com aplicativo de transporte privado. Disse que levou o corréu até a farmácia para fazer compras. Na volta, passou num local para pegar drogas. Depois disso, perto de sua casa, foi abordado por uma viatura. Respondeu que atualmente trabalha como táxi. À época, respondeu que trabalhava com uber e 99. Indagado, declarou que comprou a maconha de Gabriel por R\$ 70,00. Explicou que a porção adquirida seria consumida entre 7 e 10 dias. Explicou que prefere comprar em maior quantidade para não frequentar diariamente as bocas de fumo.

Inexiste dúvida, pois, quanto à posse do entorpecente pelo acusado. A controvérsia recai sobre a destinação da droga.

O reconhecimento da traficância ou da posse para uso pessoal depende da análise das circunstâncias estabelecidas no art. 28, §2º, da Lei 11.343/06, segundo o qual, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso sub iudice, o acusado foi flagrado na posse 73,1g de maconha separados em 4 tabletes. Além disso, havia R\$ 355,00 em espécie (notas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais) e um rolo de papel filme.

O acusado não era conhecido dos meios policiais, tampouco objeto de prévia investigação. É primário, não possui nenhuma anotação em sua ficha criminal, nem a existência de inquérito policial em curso.

A abordagem não se deu em local comumente utilizado na comercialização de entorpecente. Não se identificou nenhum usuário que teria previamente adquirido drogas do denunciado.

A maconha apreendida não se mostrou incompatível com o uso pessoal. Destaco igualmente que não estava acondicionada em pequenas porções destinadas ao varejo, mas, sim, em 4 tabletes prensados.

Aliás, tanto a quantidade não se mostrou inconciliável com o uso que o Tribunal de Justiça possui diversos precedentes desclassificando a imputação para o art. 28 da Lei de Drogas mesmo em casos envolvendo apreensões maiores.

Apelação - Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) - Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas - Recurso do Ministério Público - Réus flagrados na posse de 487g de maconha -

Desclassificação correta - Quantidade compatível com uso pessoal para os dois acusados - Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância - Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância - Operada, no curso do processo, a desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes, de rigor a proposição de transação penal e de suspensão condicional do processo - Benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e maus antecedentes - Conversão em diligência para que o representante do 'parquet' avalie eventuais propostas.

(TJSP; Apelação Criminal 1511721-06.2019.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

No mesmo sentido:

TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. Ao ser interrogado em juízo, o réu apresentou versão lógica e coerente, que traduz a impressão de condizer com a realidade. O réu, em juízo, negou a prática delituosa tráfico. Portanto, fato é que os policiais (ou quem quer que seja) não viram o réu realizando qualquer conduta típica da traficância. Apenas apreenderam pequena quantidade de drogas. FALTA DE PROVAS.

Assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a melhor solução para o caso é a desclassificação da imputação para a modalidade prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, pois, inegável que em poder do apelante foi apreendida

parte da droga, porém a mesma se destinava ao seu uso pessoal.
(TJSP; Apelação Criminal 1500342-80.2020.8.26.0633; Relator (a): Alex Zilenovski;
Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do
Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

Em caso extremamente parecido com a presente ação penal, o sujeito, que havia sido
flagrado na posse de 90g de maconha, obteve êxito em sua tese defensiva no sentido
da desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Portanto, adoto como
fundamentação a ratio decidendi desenvolvida pelo eminente Relator Dr. Marcos
Alexandre Coelho Zilli:

[...] Não há informação de que teria realizado qualquer atitude suspeita
anteriormente à sua abordagem que permitisse inferir, para além de dúvida razoável,
a sua vinculação com o tráfico. Não ofereceu qualquer resistência durante a
abordagem. Não há registro da apreensão de anotações de possível contabilidade ou
mesmo de outros instrumentos que pudessem indicar o possível preparo para futura
comercialização. A maconha apreendida era de pouca monta 90 gramas e sequer estava
acondicionada em porções individualizadas próprias para a venda no varejo. A
quantidade de dinheiro sessenta e oito reais também não pode ser considerada
exagerada a ponto de indicar a vinculação com o tráfico. O réu, por sua vez, negou
envolvimento no tráfico, admitindo a posse para o uso pessoal em seu interrogatório
judicial. A quantidade não é, por si, incompatível com aquela condição.
Assim, qualquer afirmação de tráfico haveria de partir, necessariamente, de uma
presunção, que, como se sabe, não se mostra cabível no contexto do Direito Penal.
Aliás, diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a
situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da presunção da
inocência. Logo, a alegação dada pelo próprio réu de que seria mero usuário
afigura-se plausível [...]

(TJSP; Apelação Criminal 1501754-97.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre
Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro:
11/04/2022)

Importante frisar que não havia outra modalidade de entorpecente com o acusado.
Logo, não há falar em variedade de drogas.

O valor em espécie apreendido não se revelou excessivo. O acusado declarou que
trabalhava como motorista particular, o que foi ratificado pelo corréu Luiz Otávio.
Entendo, por conseguinte, que o valor apreendido apenas levanta a hipótese da
traficância, não confirma, por si só, a tese acusatória.

É cediço que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a palavra do
agente público deve ser considerada para formação do convencimento judicial,
inclusive para condenação. Não obstante, não há falar, a priori, em presunção de
veracidade.

No Direito Público, é reconhecido, enquanto atributo dos atos administrativos, a
presunção de veracidade (os pressupostos fáticos são presumidamente verdadeiros até
prova em contrário), o que permite o exercício dos poderes de autotutela e de
imperatividade pela Administração, os quais têm aptidão para vincular particulares
independentemente da intervenção do Poder Judiciário.

Ocorre que, no Direito Processual Penal, em razão de norma de estatura
constitucional (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), a única presunção
existente milita em favor do réu.

A partir desse parâmetro, o depoimento dos policiais tem credibilidade enquanto
prova testemunhal. E, nessa condição, suas versões, assim como as das demais
testemunhas, devem ser cotejadas com os outros elementos constantes nos autos.
Importante também ter em mente a suficiência dos depoimentos dados pelos agentes de
segurança pública à luz das circunstâncias da prisão. Isto é: conhecimento
pretérito da atividade criminosa exercida pelo réu por meio de investigações
documentadas; possibilidade de reunir outras testemunhas; disponibilidade de outros
meios de prova; imprescindibilidade ou não da imediata atuação dos policiais ou
generalidade das declarações dadas em juízo. Em suma: a versão do agente público

nem é abstratamente suspeita, nem presumidamente verídica.

Na espécie, os policiais militares disseram que não presenciaram nenhuma conduta do réu que sugerisse a prática de atos destinados à comercialização de venda. Dos depoimentos dados em juízo, é possível concluir que a abordagem se deu porque o motorista não respeitou a sinalização de trânsito e, ao visualizar a viatura, fechou os vidros. Tais elementos não tem o condão de vincular o réu à traficância. Encerrada a instrução, reputo permanecer dúvida objetiva quanto ao exercício do tráfico de drogas pelo denunciado.

Como se sabe, segundo a vertente probatória do princípio da presunção de inocência, incumbe ao Ministério Público demonstrar, além de dúvida razoável, que o réu cometeu a infração penal descrita na denúncia.

As provas produzidas, portanto, revelam-se frágeis, não permitindo o reconhecimento de que o material apreendido efetivamente se destinava à comercialização.

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

A partir desses dispositivos, não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após presidir a instrução do feito, colher as provas necessárias para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da adequada interpretação do art. 156 do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo, trago à baila as lições do Professor Afrânio Silva Jardim:

[...] somente a acusação é que alega fatos, atribuindo-os ao réu. Eventual 'alegação' deste, será tão-somente aparente, vez que juridicamente deve ser reputada como mera negação dos fatos alegados na denúncia ou queixa", isso porque, no processo penal, o réu é presumidamente inocente e a dúvida sempre o favorece. Sob tal prisma, não é aplicável de forma automática, no processo penal, a distribuição do ônus da prova regulada no processo civil, de forma a transferir ao acusado o dever de demonstrar sua inocência. Urge que a regra do art. 156 do CPP seja compreendida como "a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 294-312).

Portanto, como o órgão de persecução penal, mesmo após a instrução processual, não logrou êxito em convencer o juízo de que o réu praticou a infração descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de rigor a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.

III - DOSIMETRIA

À luz do princípio da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e do critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade se encontra dentro da normalidade do tipo; o réu não possui maus antecedentes; não há provas – laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social – capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime não destoam do esperado; não há falar em comportamento da vítima na espécie. Sendo assim, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la para não fixar a pena aquém do mínimo legal, consoante determina o enunciado 231 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas especiais de diminuição ou de aumento de pena.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, considerando o quantum de pena aplicado, as circunstâncias judiciais e a primariedade, determino o cumprimento inicial em regime aberto, por força do disposto no art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber: (a) prestação de serviços à comunidade ou a uma entidade pública, pelo prazo da pena privativa de liberdade ora substituída, conforme determinações do Juízo da Execução Penal; (b) prestação pecuniária no valor correspondente a 1 salário mínimo.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

(a) CONDENAR Luiz Otávio da Silva ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, nos termos delineados na fundamentação.

(b) DESCLASSIFICAR a conduta do acusado Vinícius Cauê Pereto Pereira para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Por ser réu primário, após o trânsito redistribuam-se os autos para o Juizado Especial Criminal competente, com vistas a eventual propositura de institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/95, com base no art. 383, §2º, do Código Penal.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Não há falar em detração na espécie (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Sem indenização mínima, uma vez que não requerida (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Os réus poderão recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal).

Comunique-se a vítima, na forma do art. 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Destruição do entorpecente na forma do art. 72 da Lei 11.343/06,

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado: (i) remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e da pena de multa e, após, proceda-se ao seu recolhimento na forma do art. 686 do Código de Processo Penal; (ii) oficie-se o TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; (iii) comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça para fins estatísticos e para registros nos antecedentes criminais do acusado.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA